

1500026-94.2022.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... no local; que tem antecedente por tráfico e furto; que saiu do sistema prisional ha dois anos; que não conhece os Guarda que o prenderam." Em juízo manteve sua versão. Disse ser inocente e que está sendo acusado por estar dentro da escola. Estava lá usando drogas, pois estava abandonado. Tinha várias caixas dentro da escola, mas não avistou nenhuma caixa lá fora e nem próxima da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500026-94.2022.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500026-94.2022.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DONIZETTI SAVI

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de FERNANDO DONIZETTI SAVI, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal afirmando que em 10 de janeiro de 2022, por volta de 05h40min, nas dependências da Escola John Kennedy, situado na rua José Fiochi, nº 35, Parque Lagoa Serena, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, tentou subtrair um retroprojeto, periféricos de computadores, fios elétricos de cobre e outros objetos pertencentes à citada escola, representada por Girley de Oliveira Reis.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "o denunciado se dirigiu ao local dos fatos e, após pular o muro, arrombar as portas de acesso e danificar uma janela, ingressou no imóvel. Em seguida, passou a recolher os bens acima mencionados, separando-os na área externa para subtração. Todavia, o sistema de alarme foi disparado e a Guarda Municipal se dirigiu imediatamente ao local, tendo o denunciado sido flagrado no interior do estabelecimento, ocasião em que, ao notar a presença dos agentes, ele empreendeu fuga. Porém, o increpado foi perseguido até sua residência no bairro vizinho e, quando ingressou na garagem do imóvel, foi alcançado e preso em flagrante, tendo sido necessário o uso de força moderada e algemas para contê-lo, pois no ímpeto da fuga empreendida ofertou resistência e investiu contra os agentes públicos. Os bens que já estavam separados para subtração foram recuperados, sendo constatado, contudo, que diversos deles e

também o imóvel vitimado estavam danificados, resultando em um prejuízo aproximado de R\$ 1.443,79, conforme laudo pericial de fls. 124/127 e relatório de fl. 128. O delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois o alarme da escola disparou e ele foi surpreendido durante o ato ilícito, no que fugiu deixando os bens arrecadados no Local."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto:

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores (...)
"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".
STJ, Terceira Seção, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos.

Ficou comprovada a existência do crime e sua autoria.
A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 53/55, pelo auto de avaliação de fls. 37 e, sobretudo, pela prova oral colhida.
A autoria também é certa.

A suposta vítima, Girley de Oliveira Reis, na fase policial disse que "é representante da mantenedora "Associação Instituto Missionário", que provê os recursos necessários ao funcionamento da escola John Kennedy a qual tem sede na cidade de Pirassununga-SP e filial nesta cidade de Porto Ferreira; que, nesta data estava em Pirassununga quando foi informado que havia ocorrido um furto na escola John Kennedy desta cidade; que, não chegou a ir até a escola e veio direto a esta Delegacia onde tomou conhecimento dos fatos; que, o Gerente Financeiro José Valentin Hansen esteve no local e disse ao declarante que o autor do furto danificou o ar condicionado, o sistema de monitoramento de cameras, parte da fiação elétrica; que, segundo informado o indivíduo que invadiu o local, também danificou alguns objetos na tentativa de subtraí-los, sendo um retroprojektor, e alguns periféricos de computadores, como mouse, teclados entre outros; que, nada foi subtraído pois os Guardas Municipais chegaram pelo local tão logo o alarme disparou; que, o declarante narra que posteriormente fornecerá orçamento dos objetos que foram danificados; que, narra ainda que o autor dos fatos provavelmente pulou o muro que guarnece o local e arrombou uma janela de vidro ganhando o interior do prédio, sendo que a perícia técnica já esteve no local; que, o declarante narra que não chegou a ver o autor dos fatos detido pela GCM, sendo-lhe declinado seu nome como Fernando Donizetti Savi informando tratar-se de pessoa estranha a seu relacionamento." Em juízo manteve sua versão. Na escola viu o espaço da janela quebrado e por onde o agente teria entrado; viu os lugares em que o

agente havia mexido. Na delegacia reconheceu como objeto da escola o retroprojetor, os demais objetos poderiam ser ou não ser da escola. A escola é cercada por grades. Para entrar ele teria de cortar a grade ou pular. A grade é relativamente baixa e não é difícil de entrar. Não sabe se a grade foi cortada. O acusado não reparou os prejuízos. Não fizeram nenhum processo de recuperação dos objetos. Escola foi desativada no final de 2019. Sempre alguém ia regularmente para ver como estava o prédio. Já foi à escola várias vezes para ver o estado do prédio. Tem conhecimento de que várias vezes pessoas tiveram acesso ao espaço externo; não se lembra de acesso interno (embora tenha desconfiança disso). Todos os locais internamente eram fechados, embora tenha havido arrombamentos nos últimos tempos.

A testemunha de acusação, o guarda municipal Tiago Daniel Caramori, na fase pré processual disse que "nesta data, estava de serviço com o colega Ferreira quando foram acionados para atendimento de denúncia anônima dando conta de que poderia ter alguém no interior da Escola John Kennedy, local dos fatos, uma vez que o alarme estava disparado; Que, de imediato se deslocaram até ao local e lá constataram o alarme disparado e após solicitação, a empresa Rádio Alarme compareceu para abertura do portão; Que o depoente aguardou no local para o lado de fora, e o GCM Ferreira adentrou no interior, momento em que o indivíduo saiu correndo e pulou o alambrado; Que foram no encalço do suspeito e conseguiram detê-lo no interior da garagem da casa do mesmo, no bairro viizinho do local; Que o indivíduo antes de ser abordado resistiu e investiu contra a guarnição, sendo necessário o uso de algemas e de força moderada; Que a guarnição não chegou a se ferir devido à resistência do suspeito; Que o suspeito foi identificado como Fernando Donizetti Savi; Que indagado, disse que correu porque se assustou e alegou que estava dentro do local porque estava dormindo; Que retornaram ao local, onde constataram danos no local e que os objetos já estavam separados para serem levados; Que foi comunicado o representante do local; Que conhece o indiciado nos meios policiais por práticas anteriores de furto e por ser usuário de droga." Em juízo manteve sua versão. Disse que no espaço em que o agente pulou a cerca havia objetos separados; o acusado já escapou de outras ocorrências de furto; há muitas reclamações contra ele nas redes sociais. Não teve nova abordagem envolvendo o acusado. Sabe que naquele dia a equipe noturna da GCM teve uma solicitação para a escola. Teve um disparo durante a madrugada. Os objetos encontrados estavam do lado de fora da escola, na calçada. A testemunha de acusação, o guarda municipal Wilson Rogerio Ferreira, na fase pré processual disse que "nesta data, estava de serviço com o colega Caramuri quando foram acionados mediante denúncia anônima dando conta de que poderia ter algum indivíduo no interior da Escola John Kennedy, uma vez o alarme estava disparado; Que de imediato se deslocaram até ao local e lá constatou o alarme disparado e foi solicitado junto à empresa Rádio alarme que comparecesse para abertura do portão; Que o GCM Caramuri aguardou no lado de fora e o depoente adentrou no local, quando um indivíduo saiu correndo e pulou o alambrado; Que foram no encalço do suspeito e conseguiram detê-lo no interior da garagem da casa do mesmo, bairro viizinho; Que o indivíduo antes de ser abordado resistiu e investiu contra a guarnição, sendo necessário o uso de algemas e de força moderada; Que a guarnição não chegou a se ferir devido à resistência do suspeito; Que foi identificado como Fernando Donizetti Savi; Que indagado, disse que correu porque se assustou e alegou que estava dentro do local porque estava dormindo; Que retornaram ao local, onde constatou danos no local e os objetos já estavam separados para serem levados; Que foi comunicado o representante do local; Que conhece o indiciado nos meios policiais por práticas anteriores de furto e por ser usuário de droga; Que deseja ressaltar que denúncias recaem sobre o indiciado pela prática de outros delitos de fio na cidade." Em juízo manteve sua versão. Disse, no entanto, que os objetos deixados por Fernando estavam do lado de dentro da escola. Entrou no trabalho às 05h20min. Não participou da diligência da madrugada, mas foi avisado pelos companheiros de trabalho. Quando chegaram na escola avistaram o acusado dentro do laboratório. Entrou na escola junto com o pessoal do alarme. Não viu a forma como ele caiu após pular. A caixa com os objetos estava jogada do lado de dentro. Parte dos objetos estavam do lado de fora. Acredita que na primeira chamada o agente já teria levado a caixa para o local onde pulou. A caixa era avistável do lado de fora

da escola.

FERNANDO DONIZETTI SAVI, em declarações perante a autoridade policial disse que "nega a pratica de furto; que afirma que é usuário de crack e estava brigado em sua casa, razão pela qual estava dormindo numa escola abandonada no Bairro Lagoa Serena; que em dado momento ouviu vozes e viu os Guarda Municipais armados vindo em sua direção, razão pela qual, evadiu-se do local, sendo detido no interior de sua casa; que resistiu a prisão, uma vez que temia ser preso sem que tivesse feito nada pra isso, pois conforme disse, so estava dormindo no local; que tem antecedente por tráfico e furto; que saiu do sistema prisional ha dois anos; que não conhece os Guarda que o prenderam." Em juízo manteve sua versão. Disse ser inocente e que está sendo acusado por estar dentro da escola. Estava lá usando drogas, pois estava abandonado. Tinha várias caixas dentro da escola, mas não avistou nenhuma caixa lá fora e nem próxima da cerca do lado de dentro. Estava na escola desde às 22h. Por volta de 03h estava muito frio e como tinha uma janela aberta entrou. Não ouviu o alarme disparar nenhuma vez durante a madrugada. Não chegou a ver as caixas. Viu os guardas batendo no vidro. Quando viu a arma se apavorou e saiu correndo. Várias pessoas frequentavam o local. O local tinha muitas portas abertas e arrombadas. O alambrado tem vários lugares abertos. Qualquer pessoa pode entrar, até mesmo uma criança.

Embora tenha negado os fatos, a versão dada pelo acusado não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ficando isolada. Até porque foi incapaz de infirmar o restante do contexto probatório, que lhe é contrário, sequer apontando um motivo idôneo a motivar a prova oral colhida robusta trazida pela acusação ou explicar eventuais equívocos nas provas materiais.

Por outro lado, os depoimentos da vítima e das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Isso porque o acusado assumiu que estava no local desde as 22h. Sua declaração de que não ouvira os acionamentos do alarme é pouco crível.

Os relatos das testemunhas de acusação apontam que o acusado fugiu por determinado local da cerca, deixando objetos tanto do lado de dentro, como do lado de fora da cerca.

Fatos que deixam evidentes a tentativa de subtração.

Qualificadora do rompimento de obstáculo (artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal): para sua caracterização é necessário que a violência seja praticada contra o obstáculo que dificulta a subtração e não contra a própria coisa. Nos termos do art. 171 do Código de Processo Penal é expressamente exigida a perícia, a qual, entretanto, conforme jurisprudência, pode ser substituída por provas testemunhais quando os vestígios tiverem desaparecido.

No caso em exame, houve deterioração do ar-condicionado e da porta da cozinha conforme laudo de fl. 124/127.

Entretanto, ficou dúvida nos autos que tais deteriorações tenham sido causadas pelo agente. Até porque sua ligação direta com os objetos alvos da subtração não é clara.

Qualificadora da escalada (artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal): considera-se escalada a entrada por via anormal, que exige um esforço fora do comum do agente para que se concretize a ação delitiva. Nos termos do art. 171 do Código de Processo Penal é expressamente exigida a perícia, a qual, entretanto, conforme jurisprudência, pode ser substituída por provas testemunhais quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. No caso, ela ficou comprovada pelo laudo pericial de fl. 163/165.

A existência de sistema de segurança e de vigilância eletrônica não torna o crime impossível, conforme entendimento do STJ:

Recurso especial representativo de controvérsia provido para: a) reconhecer que é relativa a inidoneidade da tentativa de furto em estabelecimento comercial dotado de segurança e de vigilância eletrônica e, por consequência, afastar a alegada hipótese de crime impossível; b) julgar contrariados, pelo acórdão impugnado, os arts. 14, II, e 17, ambos do Código Penal; c) determinar que o Tribunal de Justiça estadual prossiga no julgamento de mérito da apelação.

REsp 1385621/MG, Rel. Min. Rogerio Shietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015. Tema 924 dos Recursos Repetitivos.

Súmula 567 do STJ. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

Impossível a incidência da insignificância em razão dos valores dos bens alvos da subtração, muito superiores a uma salário mínimo. Tais valores também impedem a incidência do privilégio e serão devidamente considerados na dosimetria.

Configurado, assim, o delito de furto qualificado, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa".

Passo a dosar as penas.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da basilar em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários.

AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.

AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.

Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos - diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...)

cumprir que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumprir que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998. (...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, "reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa" (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...)

Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima.

TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe

08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de repressão e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juizes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juizes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que a pessoa imputada possui três maus antecedentes (0001080-24.2012.8.26.0472, 0001349-34.2010.8.26.0472 e 1500177-02.2018.8.26.0472), razão pela qual aumento a pena com mais três de reclusão e 174 dias-multa.

Não se aplica aos maus antecedentes o período depurador de cinco anos (Tema 150 da Repercussão Geral do STF – HC 593.818/SC).

De notar também o considerável valor dos bens e do prejuízo (fls. 124/128, superando os R\$11.000,00) razão pela qual fixo a pena-base em seis anos de reclusão e 232 dias-multa..

Segunda etapa. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Terceira etapa. Em razão da tentativa seria o caso de diminuir a pena no seu grau mínimo, vez que o plano do agente foi interrompido apenas em seus estertores.

No entanto, em razão do pedido ministerial e do art. 3º-A do Código de Processo Penal, faço a redução no máximo legal.

A conjunção da extensão da sanção corporal com a negativa das circunstâncias judiciais indica como adequado o regime semiaberto.

No entanto, em razão do pedido ministerial e do art. 3º-A do Código de Processo Penal, o regime inicial será o aberto.

Por estas mesmas razões faço a substituição da pena privativa de liberdade pelas sanções de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-

mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR FERNANDO DONIZETTI SAVI à pena de reclusão, pelo prazo de dois anos, em regime inicial aberto, bem como a 77 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Substituo a pena por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 17 de maio de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA